

TÍTULO:	35 Concurso en caso de agrupamiento. Acreditación de la existencia de grupo (art. 65, L. 24522)
AUTOR/ES:	Taricco Vera, Germán S.
PUBLICACIÓN:	Doctrina Societaria y Concursal ERREPAR (DSCE)
TOMO/BOLETÍN:	XVI
PÁGINA:	1550
MES:	Diciembre
AÑO:	2004
OTROS DATOS:	-

35 - Concurso en caso de agrupamiento. Acreditación de la existencia de grupo (art. 65, L. 24522)

GERMÁN S. TARICCO VERA

A) Práctica del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 11, Secretaría Nº 21

A.1) Conversión en concurso preventivo. Apertura concurso como grupo económico

"Hormisur SA s/quiebra". Expediente 74.581 - Sec. Nº 21

Buenos Aires, 22 de mayo de 1996

AUTOS Y VISTOS:

1. Decretada su quiebra, Hormisur SA se presentó a fojas 104, solicitando en los términos del artículo 90 de la ley 24522, la conversión del proceso en concurso preventivo, y denunciando integrar un "conjunto económico" con las empresas Macona SA y Laveno SA.

Tanto estas últimas como las personas físicas Carlos Alberto Andolina y Luis Miguel Andolina -garantes de diversas obligaciones de las sociedades- acudieron a su vez al remedio concursal, promoviendo los respectivos procesos, que han sido remitidos a este Tribunal a los efectos de este pronunciamiento.

2. La fallida ha cumplido los recaudos formales exigidos por el artículo 92 de la ley 24522, razón por la cual -a tenor de la imperativa directiva establecida en el art. 93 de ese ordenamiento- procede dejar sin efecto la sentencia de quiebra y disponer la apertura del respectivo concurso preventivo.

Sin embargo, toda vez que -reitero- se ha denunciado su participación en un "conjunto económico", previamente es menester analizar si todos sus componentes adhirieron a la petición, y si han sido adecuadamente acreditadas la existencia y la permanencia de éste, como lo exige el artículo 65, "in fine", de la ley concursal, puesto que en caso afirmativo la decisión a dictarse deberá ajustarse a lo prescripto por el artículo 67 de ese cuerpo legal.

3. La "concursabilidad" de un agrupamiento económico constituye uno de los institutos más novedosos de la nueva normativa concursal, siendo que, en el anterior ordenamiento, sólo se tenía en consideración la existencia de ese conjunto a los efectos de la extensión de la quiebra [L. 19551, art. 165, inc. 2)].

Y muchas son, según la doctrina y jurisprudencia, las formas a través de las cuales puede plasmarse ese agrupamiento -que no necesariamente debe responder a un molde rígido-, razón por la cual para la apreciación de los recaudos legales exigidos no cabe fijar pautas de carácter general, sino estar a las peculiaridades de cada caso, utilizando un criterio de realidad (Gagliardo, Mariano: "Concurso preventivo en caso de agrupamiento", y Bergel, Salvador D.: "La concursabilidad del grupo en el proyecto de la ley de concursos" - ED - 6/11/1995 y 21/9/1994, respectivamente), máxime cuando la ley omite toda alusión a las pautas que deben tenerse en cuenta.

a) Comprensión de la solicitud a todos los integrantes del grupo

Con la precariedad cognoscitiva propia de esta etapa inicial del proceso, adelanto que estimo cumplido este requisito.

De la profusa documental acompañada en los cinco (5) juicios universales referidos *supra* y que tengo a la vista, no se advierte que, además de las sociedades ya mencionadas, existiere otro integrante del grupo, a cuya permanencia y exteriorización me referiré de seguido.

b) Permanencia de la integración del grupo

Considero que este recaudo es inherente a la forma en que se desarrollan las relaciones entre los sujetos que invocan la agrupación, esto es, a situaciones económicas o jurídicas de un pasado o presente inmediato (Gagliardo, Mariano: "Concurso preventivo en caso de agrupamiento"), y también lo aprecio satisfecho en esta liminar instancia.

Ello, al margen de las particularidades que se referirán *infra*, en razón de las garantías otorgadas por una sociedad a otras o por los garantes a todas ellas (ver fs. 263/6 y 267/8 de estos autos; fs. 86, 88 y 115 del expediente de Carlos A. Andolina; y fs. 138, 140 y 142 del expediente de Luis M. Andolina), y de la decisión en común de todas las sociedades de acudir al remedio concursal, plasmadas en las respectivas presentaciones iniciales y las resoluciones de directorio y de asamblea de que dan cuenta las correspondientes actas agregadas a las distintas causas.

c) Exteriorización de la existencia del agrupamiento

Como dije, no especifica la ley los parámetros a evaluar sobre este particular.

No obstante, autorizada doctrina ha señalado las siguientes pautas indiciarias, que aprecio configuradas aquí: i) funcionamiento de los diversos entes en una misma sede; ii) "garantías intergrupo"; y iii) existencia de vínculos organizativos o de directorio comunes (Bergel, Salvador D.: "La concursabilidad del grupo en el proyecto de la ley de concursos" - ED - 6/11/1995 y 21/9/1994).

i) **Funcionamiento en una misma sede**

Aparece acreditado que Hormisur SA y Laveno SA poseen un idéntico domicilio social, sito en la calle Moreno 1359, PB "6" (ver fs. 35 de estos autos y fs. 453 del expediente de "Laveno").

Asimismo, las tres sociedades tienen un mismo domicilio "fiscal", según surge de los requerimientos efectuados por la Dirección General Impositiva a todas ellas (ver fs. 255/7 de esta causa).

Las empresas, además, desarrollan su operatoria comercial -en mayor o menor medida- en el predio sito en la calle Bernal 1599 de la localidad de Lanús, Provincia de Buenos Aires (ver fs. 248, 252 y 304 de estos obrados).

ii) **Garantías intergrupo**

Este tipo de operaciones se advierte en las ya citadas piezas de fojas 263/6 y 267/8.

iii) **Existencia de vínculos organizativos o de directorio comunes**

Carlos A. Andolina y Luis M. Andolina aparecen como los accionistas mayoritarios de Laveno SA y Macona SA, e integraron o integran, a su vez, el directorio de ambas sociedades (ver fs. 6/9, 10/4 y 23/4 de los expedientes respectivos).

Al margen de ello, se notan otras circunstancias, calificadas también como notas distintivas del agrupamiento según la doctrina citada por la deudora en su presentación de fojas 273/9:

* **Similitud de objetos sociales**

Como expresaran los entes, y surge de los correspondientes instrumentos de constitución de ellos, Macona SA se dedica principalmente a la venta y transporte de materiales para la construcción, y Laveno SA y Hormisur SA a idénticas actividades, aunque respecto de arena, piedra y "otros áridos" la primera y de hormigón la última, quehaceres todos cuya integrabilidad es notoria.

* **Identidad de fuentes de materia prima, producción, etc.**

La misma puede deducirse de la existencia de los mismos acreedores de las empresas, entre los que pueden destacarse "Ferrosur Roca", "Loma Negra", "Canteras Piatti" y "Puma Argentina", según los informes de experto contable acompañados (ver fs. 323, 325, 326 y 330 de estos autos; fs. 433, 434, 435 y 438 de la causa "Laveno"; fs. 239 del expte. "Macona").

* **Unicidad de asesoramiento jurídico y contable**

Según surge de las respectivas presentaciones judiciales y de los informes y/o certificaciones contables obrantes en autos, todos los sujetos cuentan con el asesoramiento de los mismos profesionales.

4. Como conclusión de lo expuesto en el apartado precedente, juzgo suficientemente acreditada la existencia de un "conjunto económico" integrado por las sociedades anónimas Hormisur, Macona y Laveno.

Procede entonces determinar el trámite que quepa imprimir a sus respectivas solicitudes de apertura de concursos preventivo:

a) Aunque en forma separada, todos los procesos tramitarán por ante este Tribunal a mi cargo, en que ya estaba radicada la quiebra de Hormisur SA, lo que se comunicará al Superior mediante oficio por Secretaría a librarse en cada uno de ellos.

Ello así, en tanto esta última sociedad es la que posee mayor activo dentro del conjunto económico, tanto se consideren al efecto los últimos balances de los entes (art. 67, primer párrafo, L. 24522) como los estados del activo y del pasivo de los mismos certificados por contador público (ver fs. 142 y 315 de estos autos, fs. 278 y 281 del expte. "Laveno", y fs. 230 y 246 de la causa de "Macona").

Este trámite, señalase, se ajustará en cada proceso según las características que posea el mismo y la aplicación que quepa efectuar a su respecto de lo dispuesto por los artículos 288 y 289 de la ley 24522.

b) La sindicatura, sin perjuicio de su unicidad, será plural, pues así lo justifican el número de los concursos que tramitarán conjuntamente (cinco en total, incluidos los correspondientes a las personas físicas garantes) y la calidad de "gran concurso" que de acuerdo con lo previsto por el artículo 288 de la ley concursal cabe asignar al proceso de "Hormisur".

Consiguientemente, la función desarrollada individualmente hasta ahora por la contadora Miriam Finocchio será complementada con la designación de otro síndico que será designado de la lista única actualmente obrante en el Tribunal -limitación por la cual prescindiendo de la calificación prevista en el art. 253, inc. 5), LC-, a cuyo fin se fija la audiencia del día 28 de mayo de 1996, a las 10:10 hs, cuya celebración se anoticiará en las tablillas del Tribunal y se comunicará a la Excelentísima Cámara a través del oficio de estilo.

Ambos síndicos intervendrán en la totalidad de los procesos concursales -tanto los de las sociedades integrantes del grupo como los de los garantes- de lo que se dejará la pertinente constancia, y sus funciones se coordinan así: la contadora Finocchio tendrá a su cargo las tareas correspondientes a la verificación de los créditos, y al funcionario concursal por designar le competará el control de los actos de los concursados en los términos de los artículos 16 y 17 de la ley 24522 y la realización de las tareas investigativas en orden a aquellos que se consideraren susceptibles de ser revocados. Las labores que excedan esos ámbitos deberán ser desarrolladas en conjunto por ambos síndicos (vgr. presentación de informe general).

En lo que hace a la eventual distribución de honorarios, establécese que la misma se evaluará oportunamente, según las tareas efectivamente desarrolladas por cada síndico.

c) En lo demás, deberá estarse a lo previsto por el artículo 67 y concordantes de la ley 24522.

5. Encontrándose entonces reunidos los recaudos exigidos por el artículo 92 de la ley 24522 y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 14 de ese ordenamiento procede:

a) Declarar abierto el concurso preventivo de Hormisur SA -inscrita en la IGJ el 21/2/1994 bajo el número 1401, Libro 114, Tomo "A" de sociedades anónimas-, proceso al que, en virtud de no apreciarse configurada ninguna de las circunstancias referidas en el artículo 288 de la mentada ley, califico como "gran concurso".

b) Publicar edictos por cinco (5) días y en los términos de los artículos 27 y 28 de la ley 24522 en el Boletín Oficial de la Nación, en el de la Provincia de Buenos Aires, y en el diario La Nación, bajo apercibimiento de tener a la concursada por desistida de su solicitud (art. 30 de dicha normativa). La convocataria debe presentar los recibos que acrediten el cumplimiento de las publicaciones dentro del quinto día de notificada la presente, así como también acreditar la efectiva publicación dentro del quinto día posterior a su primera aparición.

Por razones de economía, en esas piezas edictales se anoticiará también la apertura -que se dispone por separado- de los concursos preventivos de las demás empresas integrantes del agrupamiento y de los garantes.

c) Hacer saber a los acreedores la existencia de este juicio para que hasta el 19/7/1996 presenten al síndico sus pedidos de verificación.

d) Intimar a la concursada para que dentro del término máximo de tres (3) días deposite en el Tribunal -a efectos de su intervención por parte del actuario en los términos del art. 14, inc. 5), LC- los libros que lleve referidos a su situación económica, y -en una cuenta a la orden de Tribunal y perteneciente a estos autos- la suma de ochocientos pesos (\$ 800) que se estima "prima facie" menester para solventar los gastos de correspondencia; todo ello bajo apercibimiento de lo dispuesto por el artículo 30 del mismo cuerpo legal.

e) Comunicar la apertura de este concurso preventivo al Registro de Juicios Universales -en tanto no se han reglamentado aún el funcionamiento y la organización del Registro Nacional de Concursos y Quiebras al que alude el art. 295 de la ley vigente-, al que se le requerirán informes acerca de la existencia de otros anteriores, a la Excelentísima Cámara de Apelaciones en lo Comercial, y al Registro Público de Comercio, quien además deberán informar sobre el nombre y domicilio registrado de todos los integrantes del órgano de administración de la convocataria, y sobre los libros de contabilidad y otros rubricados, así como también autorizaciones de medios mecánicos si las hubiere.

f) Mantener la inhibición general de la concursada para disponer y/o gravar sus bienes registrables decretada a fojas 41/6, apartado II, punto 4.

g) Hacer saber que:

g.1) la sindicatura deberá presentar el informe que establece el artículo 35 de la ley 24522, el 13/9/1996, y el previsto por el artículo 39 de ese mismo ordenamiento el 25/10/1996;

g.2) el plazo con el que contará el Tribunal para dictar la resolución establecida en el artículo 36 de la ley concursal vence el 27/9/1996, y aquél para pronunciar la prevista en el artículo 42 de ese texto legal, el 22/11/1996; y

g.3) la deudora podrá presentar la propuesta de categorización de acreedores a la que hace referencia el artículo 41 de la ley concursal hasta el 11/10/1996, contando con plazo para hacer pública su propuesta de acuerdo preventivo (art. 43, penúltimo párrafo, LC) hasta el 21/2/1997, en tanto el período de exclusividad vence el 21/3/1997.

h) Fijar la audiencia informativa prevista por el artículo 45, penúltimo párrafo, de la ley 24522 para el 14/3/1997 a las 10.10 hs, acto que se realizará en la sala de audiencias del Tribunal.

i) Constituir el Comité Provisorio de Acreedores que actuará en el proceso hasta tanto se dicte la resolución de categorización aludida en el artículo 42 de la ley concursal, designando como integrantes de la misma a Ferrosur Roca SA, Banco Mayo Coop. Ltda. y Puma Argentina SA, en razón de ser los tres acreedores quirografarios de mayor monto denunciados por la concursada [art. 14, inc. 11), LC].

j) Levantar la prohibición de salida del país que pesaba sobre Marcelo Daniel Mac Donald, disponiendo que la misma regirá únicamente para ausencias sin la pertinente autorización judicial por un plazo mayor de cuarenta (40) días, debiendo comunicarse al Tribunal dicha salida del país si se la efectúa por un lapso menor (art. 25, LC).

6. La concursada deberá confeccionar y diligenciar las comunicaciones ordenadas en el apartado 5, a excepción de la dirigida a la Excelentísima Cámara -que se cursará por Secretaría-, presentando las piezas a confornte y acreditando su diligenciamiento dentro del quinto y décimo día de notificada de la presente, así como también notificar de su designación a los integrantes del comité provisorio de acreedores, compitiendo a la sindicatura fiscalizar el cumplimiento de ello y peticionar en consecuencia.

Asimismo, deberá agregar copia íntegra y certificada del instrumento obrante a fojas 267/8, recaudo que se le exige *por segunda vez*.

7. Por todo lo expuesto, RESUELVO:

a) Convertir el trámite de la quiebra de Hormisur SA en concurso preventivo; b) declarar acreditada la existencia de un "conjunto económico" formado por dicha empresa junto con Macona SA y Laveno SA; c) proveer la apertura de aquel concordato en los términos establecidos supra; y d) disponer que junto con el mismo tramitarán -aunque en forma separada y con las modalidades individuales que cada caso imponga- los procesos concursales de aquellos entes y de las personas físicas Carlos Alberto Andolina y Luis Miguel Andolina -garantes de todas ellas-, a los cuales se provee simultáneamente en los respectivos expedientes.

8. Modifíquese la carátula y el libro de entradas de Secretaría y agréguese copia de la petición de conversión y de esta sentencia en el legajo de copias formado de acuerdo con el artículo 279 de la ley 24522.

9. Notifíquese.

Miguel F. Bargalló (Juez)

A.2) Apertura concurso preventivo. Rechazo acreditación existencia de "conjunto económico"

PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN

90236 - "Jocri SA s/concurso preventivo" - Sec. Nº 21

Buenos Aires, 1 de marzo de 2002

I - Agréguese las constancias acompañadas

II - AUTOS Y VISTOS:

1. Jocri SA solicitó la apertura de su concurso preventivo en los términos de la ley 24522, denunciando integrar un conjunto económico con Hyppoleder SA quien también acudiera al remedio concursal, promoviendo el respectivo proceso.

2. La convocataria ha cumplido los recaudos formales exigidos por la ley, razón por la cual procede disponer la apertura del respectivo concurso preventivo.

Sin embargo, toda vez que -reitero- se ha denunciado su participación en un "conjunto económico", previamente es menester analizar si han sido adecuadamente acreditadas la existencia y la permanencia de éste como lo exige el artículo 65, "in fine", de la ley concursal, puesto que en caso afirmativo la decisión a dictarse deberá ajustarse a lo prescripto por el artículo 67 de ese cuerpo legal.

3. Destácase que como lo sostuve en los autos "Hormisur SA s/concurso preventivo" en trámite por ante este Juzgado y Secretaría, la "concursabilidad" de un agrupamiento económico constituye uno de los institutos más novedosos de la nueva normativa concursal, siendo que, el anterior ordenamiento, sólo tenía en consideración la existencia de ese conjunto a los efectos de la extensión de la quiebra [art. 165, inc. 5), L. 19551].

Y muchas son, según la doctrina y la jurisprudencia, las formas a través de las cuales puede plasmarse ese agrupamiento -que no necesariamente debe responder a un molde rígido- razón por la cual para la apreciación de los recaudos legales exigidos no cabe sentar pautas de carácter general, sino estar a las peculiaridades de cada caso, utilizando un criterio de realidad (Gagliardo, Mariano: "Concurso preventivo en caso de agrupamiento", y Bergel, Salvador D.: "La concursabilidad del grupo en el proyecto de ley de concursos" - ED - 6/11/1995 y 21/9/1994 respectivamente) máxime cuando la ley omite toda alusión a las pautas que deben tenerse en cuenta.

En la especie la convocataria ha manifestado que la vinculación de las dos empresas radica en que "Jocri SA" fábrica monturas y accesorios para equitación, dedicándose "Hyppoleder SA" a exportar lo producido por la anterior (ver fs. 87).

Adelanto que no aprecio que se den en el "sub lite" los elementos necesarios para la configuración de un "conjunto económico".

Destácase que de la documental acompañada en los dos juicios universales referidos supra y que tengo a la vista, surge que: i) no poseen un idéntico domicilio social; ii) cada una opera con distintas cuentas bancarias y no aparecen avales otorgados por una a favor de la otra; iii) los directores de las sociedades no son los mismos, y iv) los acreedores tampoco resultan ser idénticos.

4. Como conclusión de lo expuesto en el apartado precedente, no juzgo suficientemente acreditada la existencia de un "conjunto económico", integrado por las sociedades "Jocri SA" e "Hyppoleder SA".

III - Sentado ello, y encontrándose reunidos los recaudos exigidos por los artículos 1, 2, 11 y 12 de la ley 24522 y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 14 de la misma, RESUELVO:

1. Declarar abierto el concurso preventivo de Jocri SA -inscripta en la IGJ el 28/2/1977, bajo el número 468, Libro 84, Tº "A" de SA, proceso al cual, en virtud de encontrarse configurada la causal establecida por el artículo 288, inciso de la citada ley, califico como "Gran".

2. Hacer saber que el 7 de marzo de 2002, a las 10.10 hs, se procederá al sorteo público del síndico que intervendrá en estos autos que será desinsaculado de la lista de la categoría "B", en tanto las características de esta causa no ameritan la elección de un funcionario perteneciente a la categoría "A" [art. 253, inc. 5), LC]. Colóquese aviso en las tablillas del Tribunal.

3. Disponer la publicación de edictos por cinco días en los términos de los artículos 27 y 28 de la ley 24522 en el Boletín Oficial y en La Nación bajo apercibimiento de tener a la concursada por desistida de su solicitud (art. 30, L. 24522).

La misma deberá presentar los recibos que acrediten el cumplimiento de las publicaciones dentro del quinto día de aceptado el cargo por el síndico que se desinsacule, así como también acreditar la efectiva publicación dentro del quinto día posterior a su primera aparición.

4. Hacer saber a los acreedores la existencia de este juicio para que hasta el 16 de mayo de 2002 presenten los títulos justificativos de sus créditos a la sindicatura.

5. Intimar a la concursada para que dentro del plazo máximo de tres (3) días deposite en el Tribunal -a efectos de su intervención por el Actuario en los términos del art. 14, inc. 5), L. 24522- los libros que lleve referidos a su situación económica, y - en una cuenta a la orden del Tribunal y perteneciente a estos autos- la suma de pesos cuatrocientos (\$ 400) que se estiman "prima facie" menester para solventar los gastos de correspondencia, todo ello bajo apercibimiento de lo dispuesto por el artículo 30 del mismo cuerpo legal.

6. Comunicar la apertura de este concurso preventivo al Registro de Juicios Universales -en tanto no se han reglamentado aun el funcionamiento y la organización del Registro Nacional de Concursos y Quiebras al que alude el art. 295 de la ley vigente- al que se le requerirán informes acerca de la existencia de otros anteriores, a la Excelentísima Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial y al Registro Público de Comercio.

7. Decretar la inhibición general de bienes de la concursada a cuyo fin líbrense los oficios y testimonios correspondientes, en su caso en los términos de la ley 22172, a los Registros de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal y de la Provincia de Buenos Aires y a los Registros de la Propiedad Automotor que correspondan.

8. Hacer saber que:

a) la sindicatura deberá presentar el informe que establece el artículo 35 de la ley 24522 el 28 de junio de 2002, y el previsto por el artículo 39 de ese mismo ordenamiento el 27 de agosto de 2002;

b) el plazo con el que contará el Tribunal para dictar la resolución establecida por el artículo 36 de la ley concursal vence el 15 de julio de 2002 y aquél para pronunciar la prevista en el artículo 42 de ese texto legal el 24 de setiembre de 2002;

c) la deudora podrá presentar la propuesta de categorización de acreedores a la que hace referencia el artículo 41 de la ley concursal hasta el 12 de agosto de 2002, contando con el plazo para hacer pública la propuesta de acuerdo preventivo (art. 43, penúltimo párrafo, LC) hasta el 11 de junio de 2003, en tanto el período de exclusividad vence el 10 de julio de 2003.

9. Fijar la audiencia informativa prevista por el artículo 45, último párrafo, de la ley 24522 para el 1 de julio de 2003 a las 11.00 hs, acto que se realizará en la sala de audiencias del Tribunal.

10. Hacer saber a Jorge Antonio Canaves (LE 1.810.701) la prohibición para viajar al exterior sin la pertinente autorización judicial, por un plazo mayor de cuarenta (40) días, debiendo comunicar al Tribunal dicha salida del país si se la efectúa por un lapso menor (art. 25, LC).

11. Resérvense los legajos de acreedores acompañados por la concursada, los que serán retirados por el síndico dentro del plazo de 72 hs. de aceptado el cargo, haciendo saber a los interesados que podrán concurrir a efectuar las compulsas pertinentes al domicilio del mismo.

12. Para formar el comité provisorio de acreedores, entre los denunciados por la deudora designase aquellos cuyos créditos son los de mayor importe, tales Dapelli SA, Banco Credicoop Coop. Ltda. y Arianne Trade SA.

Notifíquese a los mismos, encomendándose a la concursada cumplir con la confección y el diligenciamiento de las cédulas debiendo la sindicatura controlar el efectivo cumplimiento de la notificación.

IV - La concursada deberá confeccionar y diligenciar las comunicaciones ordenadas en el apartado III -ptos. 6 y 7-, a excepción de la dirigida a la Excelentísima Cámara -que se cursará por Secretaría- presentando las piezas a confronte y acreditando su diligenciamiento dentro de los días quinto y décimo -respectivamente- de notificada la presente, siendo competencia de la sindicatura el control del cumplimiento y vigencia de lo ordenado por el Tribunal.

V - El síndico deberá, en la oportunidad de presentar el informe previsto por el artículo 39 de la ley concursal, rendir cuentas del destino de las sumas percibidas en concepto del arancel establecido en el artículo 32 de dicho ordenamiento legal, acreditando, en su caso, los gastos incurridos.

VI - Con copia del escrito a despacho y del presente decreto, fórmese el legajo de copias que prevé el artículo 279 de la ley 24522.

Miguel F. Bargalló (Juez)

B) Práctica del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 9, Secretaría N° 17

B.1) Providencia previa de acreditación de grupo económico

PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN

86010 - OSMATA s/concurso preventivo (5/10/2001) - Juzgado N° 9 - Secretaría N° 17

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2001

OMISSIS ..

VI - Rechazada la denuncia efectuada a fojas 1110/7, corresponde pronunciarse sobre la petición de aplicar a este concurso preventivo, y al solicitado por el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la República Argentina, en adelante SMATA, el régimen del "concurso en caso de agrupamiento" previsto por el artículo 65 de la ley concursal habiendo denunciado ambas presentantes conformar un agrupamiento (ver autos "SMATA s/concurso preventivo" - expte 86009).

A tal fin, señálase que OSMATA es una obra social de carácter sindical con la personería gremial prevista en el artículo 1, inciso a), de la ley 23660, calificable como persona jurídica de carácter privado tal como fue anticipado en el punto III de estos considerandos.

A su vez, SMATA es una asociación sindical con personería gremial de conformidad con el artículo 23 de la ley 23551, calificable también como persona jurídica de carácter privado en los términos del artículo 33, segundo párrafo, inciso 2), del Código Civil.

Asimismo, las partes invocan la existencia de especiales vínculos existentes entre ambas y solicitan se las considere como integrantes de un "conjunto económico", "agrupamiento", o "grupo económico", cualquiera sea la definición dada a estos conceptos, detallando los extremos fácticos que acreditan su pedido.

VII - Análisis de la existencia de conjunto económico, agrupamiento o grupo económico

La ley concursal alude indistintamente en todo el capítulo al "conjunto económico" (art. 65, quinto párrafo, LC), "agrupamiento" (arts. 65, 66, 67, 68, LC) y "grupo económico" (art. 66, "in fine", LC) sin precisar su concepto.

Sin embargo, la denominación de conjunto económico, en principio, tiene estricta raigambre fiscal y laboral, no existiendo un concepto unívoco ni elementos orientadores que lo definan (conf. Otaegui, Julio C.: "Concentración societaria" - Ed. Ábaco - Bs. As. - 1984 - pág. 235).

Por su lado, el término agrupamiento alude a uniones de colaboración o vínculos de coordinación, reservándose el nombre "grupos económicos" para aquellos en los que existen relaciones de subordinación con los miembros que lo componen, que es el único supuesto que considero alcanzado por la norma concursal (ver Favier Dubois, Eduardo M. (h): "El grupo de sociedades en concurso: aspectos generales" - ERREPAR - DSE - N° 101 - abril/1996 - T. VII - pág. 885 y ss.).

En efecto, cuando la ley concursal alude a los requisitos de configuración del supuesto de hecho del artículo 65 se refiere exclusivamente a los *grupos económicos*, por cuanto sólo en este tipo se configuran los restantes recaudos de admisibilidad del capítulo, que se verán en el capítulo que sigue.

VIII - Recaudos exigidos por el artículo 65 de la ley concursal

Efectuadas estas aclaraciones corresponde analizar cuáles son los requisitos de admisibilidad del régimen y si en el caso concreto éstos se configuran.

Ellos son: 1) existencia de una pluralidad de sujetos de derecho con personalidad jurídica diferenciada (personas físicas o jurídicas); 2) relación de subordinación y dirección "unificada" que implica el poder de fijar la política económica; 3) explotación de actividades mercantiles integradas o relacionadas entre sí; 4) vocación de permanencia en el tiempo, y 5) suficiente exteriorización (conf. Favier Dubois, Eduardo M. (h): "El grupo de sociedades en concurso: aspectos generales" - ERREPAR - DSE - N° 101 - abril/1996 - T. VII - págs. 885 y ss. y Bruzzo, Mario O.: "Algunas consideraciones acerca del grupo económico en materia concursal" - VIII Congreso Argentino de Derecho Societario, IV Congreso Iberoamericano de Derecho Societario y de la Empresa - Universidad Nacional de Rosario - Santa Fe - 2001 - T. V. - págs. 37/48).

Sentado ello, corresponde señalar que el hecho de no tratarse de sociedades comerciales sino de una obra social y de un sindicato exige una prudente adecuación de la normativa aplicable de modo de no frustrar las finalidades legales.

En la especie, no cabe duda que en virtud de lo dispuesto por el artículo 1 de la ley 23660 y el artículo 23 de la ley 23551, ambos presentantes poseen personalidad jurídica propia y diferenciada (*primer requisito*).

Por su lado, respecto de la explotación de actividades económicas (*tercer requisito*), ella debe entenderse cumplida no por la explotación económica de cada uno, ya que el sindicato no la realiza, sino por el hecho de que las actividades de la obra social se cumplen utilizando los bienes del sindicato (art. 32, L. 23660) y benefician a sus miembros [arts. 5, 7 y 12, inc. a), L. 23660].

En cuanto a la relación de subordinación (*segundo requisito*) de OSMATA respecto de SMATA, ésta surge evidente teniendo en cuenta que *el órgano de conducción y administración de la obra social es un consejo directivo integrado por cinco titulares elegidos por el sindicato* a través de su propio consejo directivo nacional (art. 8, estatuto social de OSMATA).

A su vez, el consejo directivo de la asociación sindical es elegido por los afiliados (art. 111, estatuto de SMATA) y su gestión es aprobada por la Asamblea General de Delegados Congressales (art. 38, estatuto de SMATA).

Se advierte, pues, que, existe una relación de subordinación entre ambos sujetos, aun cuando no es fácilmente subsumible el caso en ninguna de las dos clasificaciones clásicas de control que resultan del artículo 33 de la ley de sociedades: "interno" y "externo" (conf. Nissen, Ricardo: "Ley de sociedades comerciales" - Ed. Ábaco - Bs. As. - 1993 - T. I - págs. 323 y ss.).

En efecto, si bien la influencia es ejercida por el sindicato a través de la elección del órgano de administración de la obra social, al no tratarse de sociedades no es posible concluir en la existencia de "*control interno*" [art. 33, inc. 1), LS] pues no existen participaciones accionarias, ni órgano de gobierno de la obra social conformado por la voluntad de sus asociados, aun cuando éstos sean los titulares del patrimonio de aquélla [art. 12, inc. a), L. 23660].

Desde otro punto de vista, tampoco sería posible encuadrar el caso en la clase de "*control externo*" por "especiales vínculos" [art. 33, inc. 2), LS], puesto que la subordinación no nace de un "contrato" entre ambos integrantes del grupo sino del propio "estatuto" de la obra social, cuerpo normativo que no podría considerarse externo al sujeto de derecho.

Dicho control tiene las características propias que resultan de los siguientes hechos: 1) el patrimonio de la obra social pertenece a sus afiliados (art. 12, L. 23660); 2) el órgano de administración de la obra social es elegido por el órgano de administración de SMATA (art. 8, estatuto de OSMATA) haciendo uso de una de las opciones que admite el artículo 12, inciso a), de la ley 23660; 3) el órgano de administración de SMATA es elegido directamente por sus afiliados (art. 111, estatuto SMATA); 4) la gestión, memoria y balances de la obra social son aprobados por su propio órgano de administración [art. 14, inc. j), estatuto de OSMATA]; 5) la gestión, memoria y balance del órgano de administración de SMATA es aprobada por la Asamblea General de Delegados Congressales (art. 38, estatuto SMATA).

En consecuencia, se trataría de una suerte de tercer género de control al que podría denominarse provisoriamente como "control estatutario", en tanto cumple las exigencias de la figura: por vía estatutaria y en forma directa el consejo directivo de SMATA designa al consejo directivo de OSMATA. Y por la misma vía, pero en forma indirecta el consejo directivo de SMATA aprueba los balances de OSMATA.

En cuanto a los dos requisitos restantes, la permanencia del grupo (*cuarto requisito*) resulta de su propia estructura de funcionamiento ya que por tratarse de una obra social sindical no puede funcionar desvinculada del sindicato al cual pertenece (ver escrito de fs. 451). Es que su activo se conforma con un porcentaje del aporte y las contribuciones de los trabajadores y empleadores al sindicato (art. 16, L. 23660) quien tiene a su cargo la administración de la misma (art. 12, L. 23660) y sus beneficiarios son los afiliados a aquél (arts. 1 y 4, estatuto de OSMATA).

En tanto la exteriorización (*quinto requisito*) ha sido acreditada: 1) por la publicidad dada en la memoria y balance de SMATA (ver Anexo VII de la presentación en concurso de SMATA), 2); por la identidad del domicilio social, de la sede de administración y fiscal de ambas; 3) por la prestación de garantías recíprocas en los préstamos celebrados con el Banco de la Nación Argentina y 4) por el aprovechamiento de inmuebles de una para desarrollar actividades de otra (conf. JNCom. N° 11, "in re" "Hormisur SA s/conc. prev." - 22/5/1996 - LL - 27/2/1997 y Vaiser, Lidia: "Un fallo ponderable sobre terreno resbaladizo" - ED).

Consecuentemente, corresponde admitir la pretensión de encuadrar ambos concursos bajo el régimen de "concursos en caso de agrupamiento" por conformar ambos presentantes un particular "grupo económico" (art. 65, LC).

IX - A todo evento, para el caso de no compartirse esta posición, la pretensión sería subsumible bajo el régimen del "concurso en caso de garantes", teniendo en cuenta que "quienes garantizasen por cualquier acto jurídico la obligaciones de un concursado, exista o no agrupamiento..." (art. 68, LC) pueden solicitar el acogimiento a este régimen.

En efecto, en el caso en examen ambas partes se han brindado garantías recíprocas -intragrupos- al haber: a) garantizado SMATA el préstamo hipotecario (U\$S 4.100.000 aprox.) efectuado por el Banco Nación (ver fs. 452/3) a OSMATA y, a la inversa, al haber hecho lo propio ésta respecto del préstamo otorgado por dicha entidad a la primera (U\$S 5.900.000 aproximadamente; ver fs. 3343 de SMATA); b) al haber cedido a dicho banco los créditos sobre los aportes y contribuciones sindicales futuros de empleadores y trabajadores en garantía de las obligaciones de ambas (ver escrito de fs. 452/3), y c) al haber subsidiado SMATA a OSMATA con fondos propios, previa decisión de su órgano de gobierno y administración (ver fs. 3360 del concurso de SMATA) no siendo necesario que una de las personas haya garantizado *todo el pasivo* de la otra sino una cantidad de obligaciones de suficiente entidad (conf. "Saiegh Salim s/conc. prev." - CNCom. - Sala B - 28/12/2000).

Consecuentemente, aún de considerar que SMATA y OSMATA no conforman un grupo económico, la petición de concursamiento bajo el régimen del capítulo será admitida.

Todo ello encuentra apoyo en la tendencia actual es la de adoptar un criterio amplio respecto de esta novedad introducida por la ley 24522 (conf. Baglietto: "Encuadre del grupo económico frente al concurso de agrupamiento" - ED - 25/11/1997), dado que el objeto principal del instituto beneficiaría -en principio- tanto a deudores como a acreedores (conf. Raisberg, Claudia: "El socio oculto y el concurso del garante" - VIII Congreso Argentino de Derecho Societario - IV Congreso Iberoamericano de Derecho Societario y de la Empresa - Universidad Nacional de Rosario - Santa Fe - 2001 - T. V - pág. 261 y ss.).

En efecto, para el deudor importa una menor burocracia y costo al tramitar ambos concursos ante un mismo juzgado así como la atenuación del régimen de mayorías y la posibilidad de prevenir la crisis antes de que sea irreversible al posibilitar el concursamiento de algunos sin encontrarse en estado de cesación de pagos.

A su vez, los acreedores -no obstante algunas desventajas- tendrían un control multidireccional del pasivo y del activo de todos los integrantes del grupo, no se verían afectados por el voto recíproco de los concursados en virtud de la exclusión dispuesta por el artículo 67 de la ley concursal, "in fine" y -en caso de quiebra- sería más fácil investigar y promover acciones de recomposición patrimonial [arts. 118, 119, 161, 162 y 173, LC] al tramitar ambos concursos ante el mismo juzgado y haber intervenido una misma sindicatura.

X - Por ello, RESUELVO: ... 2) Hacer lugar a la apertura del concurso preventivo bajo el régimen del "concurso en caso de agrupamiento" previsto por el artículo 65 de la ley concursal, debiendo estarse a las resoluciones respectivas. 3) Agregar una copia del presente en los autos "SMATA s/concurso preventivo", expediente 86009.

Eduardo M. Favier Dubois (h) (Juez)